

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2024-3]일부 변경된 집합금지명령의 대상적격성 및 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간 준수 여부

《【문제3】 A시장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거한 집합금지명령을 2024. 5. 1. 공고하면서 관내 다중이용시설을 대상으로 2024. 5. 6.부터 매일 22시에서 다음날 06시 사이의 영업을 제한하였는 바, 그에 대하여 유흥주점 업주 甲은 2024. 5. 27. 취소소송을 제기하였고, 2024. 9. 5. 현재 소송 계속 중이다. 한편, 예방조치에도 불구하고 감염병 확산세가 급등하자 A시장은 2024. 5. 31.부터 관내 다중이용시설의 영업제한 시간을 매일 20시에서 다음날 07시까지로 늘리는 내용의 집합금지명령을 2024. 5. 29. 공고하였다. 음식점 업주 乙은 해외에 체류하다가 귀국하여 2024. 6. 8. 자신의 업소에 부착된 공고문 및 안내문을 보고 비로소 그 명령을 알게 되었고, 2024. 8. 30. 그에 대하여 취소소송을 제기하였다. 甲의 소송이 대상적격을 갖춘 것인지와 乙의 소송이 적법한 기간 내 제소된 것인지를 검토하시오. (25점)》

<문제3> 일부 변경된 집합금지명령의 대상적격성 및 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 집합금지명령에 대하여 취소소송을 제기한 후 소송 계속 중 명령의 내용이 변경되었고, 乙은 변경된 집합금지명령을 뒤늦게 알게 된 후 이에 대한 취소소송을 제기하였다. 쟁점으로 <甲의 소송이 대상적격을 갖추었는지>와 <乙의 소송이 제소기간을 준수하여 적법하게 제기되었는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 소송이 대상적격을 갖춘 것인지와 乙의 소송이 적법한 기간 내 제소된 것인지를 검토한다.

II. 집합금지명령의 대상적격 (甲의 소송)

1. 일반처분의 처분성 및 대상적격

(1) 처분의 개념과 일반처분

- 행정소송법 제2조 제1항 제1호의 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 등을 의미한다. 이 중 일반처분은 불특정 다수인을 상대로 특정한 구체적 사건을 규율하는 행정행위로서 처분성이 인정된다.

(2) 사안의 판단

- A시장의 2024. 5. 1.자 집합금지명령은 관내 다중이용시설 업주라는 불특정 다수인을 상대로 영업시간을 제한하여 의무를 부과하는 일반처분으로 대상적격이 인정된다.

2. 소송 계속 중 변경처분과 대상적격의 존속

(1) 판례의 태도

- 판례는 소송 계속 중 당초처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가하거나 변경하는 일부 변경처분이 있는 경우, 당초처분은 소멸하지 않고 그 성질이 허용하는 한 변경된 내용의 범위 내에서 여전히 존속한다고 판시한다. 따라서 원고는 당초처분을 대상으로 소송을 계속할 수 있다.

(2) 사안의 판단

- A시장의 2024. 5. 29.자 집합금지명령은 당초 영업제한 시간(22시~06시)을 매일 20시~07시로 늘리는 내용으로서, 당초처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·확장하는 변경처분이다. 따라서 당초 2024. 5. 1.자 처분은 여전히 효력을 유지하므로 甲의 소송은 대상적격을 상실하지 않는다.

III. 고시·공고에 의한 처분의 제소기간 (乙의 소송)

1. 제소기간 기산점에 관한 판례의 태도

(1) 일반적 원칙

- 행정소송법 제20조 제1항에 따라 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다.

(2) 고시·공고에 의한 일반처분의 특징

- 판례는 불특정 다수인을 상대로 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우, 그 처분에 이해관계를 갖는 사람은 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날에 그 처분이 있음을 알았다고 보아야 한다고 판시한다.

2. 사안의 판단 및 제소기간 산정

(1) 기산일의 확정

- A시장의 2024. 5. 29.자 집합금지명령은 2024. 5. 31.부터 효력이 발생하도록 공고되었다. 따라서 불특정 다수인에 대한 일반처분으로서 乙이 실제로 안 날(2024. 6. 8.)과 무관하게 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분이 있음을 안 것으로 의제된다.

(2) 제소기간 도과 여부 검토

- 초일불산입 원칙에 따라 2024. 6. 1.부터 기산하여 90일이 되는 날은 2024. 8. 29.이다. 乙은 이보다 하루 늦은 2024. 8. 30.에 취소소송을 제기하였으므로, 제소기간을 경과하였다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송에 대한 적용

- A시장의 집합금지명령은 일반처분으로서 처분성이 인정되고, 후속 변경처분이 당초처분을 소멸시키는 대체적 변경처분이 아니라 일부 확장·변경하는 처분이므로 甲이 제기한 취소소송의 대상은 여전히 존속하여 대상적격을 갖춘다.

2. 乙의 소송에 대한 적용

- 乙은 일반처분의 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분이 있음을 안 것으로 의제되므로 제소기간의 종기는 2024. 8. 29.이 된다. 乙이 해외 체류 등의 사정으로 실제로 2024. 6. 8.에 알았다 하더라도 기산일이 변경되지 않으므로 2024. 8. 30.에 제기한 소는 부적법하다.

V. 결론

1. 甲의 소송

- 甲의 소송은 처분성이 인정되는 일반처분을 대상으로 하고, 소송 계속 중의 변경처분에도 불구하고 대상적격이 유지되므로 적법하다.

2. 乙의 소송

- 乙의 소송은 실제 안 날이 아닌 효력 발생일을 기준으로 제소기간이 기산되므로 90일을 경과하여 제기된 부적법한 소로서 법원에 의해 각하되어야 한다.

<보충 - 乙의 경우 제소기간 도과 판단에 대한 부가 설명>

I. 문제의 제기

- 행정소송법 제20조는 취소소송의 제소기간을 처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있는 날부터 1년으로 제한하고 있다. 사안의 乙은 해외 체류라는 불가피한 사정으로 일반처분의 공고 및 효력 발생 사실을 뒤늦게 알았음에도, 법원이 효력 발생일을 기산점으로 삼아 90일의 제소기간 도과를 이유로 소를 각하하는 것은 가혹하다는 지적이 존재한다. 이하에서는 국민의 실질적 권리 구제라는 관점에서 처분이 있는 날부터 1년의 규정을 적용할 수 없는 법리적 한계를 규명하고, 구체적 타당성과 법적 안정성의 조화 방안 및 대안적 소송법상 구제 수단을 고찰한다.

II. 행정소송법 제20조 제1항과 제2항의 법리적 관계

1. 주관적 제소기간과 객관적 제소기간의 누적적 적용

- 행정소송법 제20조 제1항의 안 날부터 90일(주관적 제소기간)과 제2항의 있는 날부터 1년(객관적 제소기간)은 선택적 관계가 아니다. 두 기간은 병렬적으로 적용되며, 둘 중 어느 하나의 기간이라도 먼저 경과하면 소송을 제기할 수 없게 되는 누적적(제한적) 관계에 있다.

2. 일반처분에서 안 날의 의제(간주) 효력

- 대법원 판례에 따르면 고시·공고에 의한 일반처분의 경우, 처분의 이해관계인은 현실적으로 고시 사실을 알았는지 여부와 무관하게 고시가 효력을 발생하는 날에 처분이 있음을 안 것으로 의제된다.

(1) 90일 기간의 즉시 작동

- 乙의 경우, 실제 귀국하여 안 날인 2024. 6. 8.과 상관없이 법적으로는 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분을 안 것으로 취급된다. 이로써 안 날부터 90일이라는 주관적 제소기간이 2024. 6. 1.부터 즉시 가동된다.

(2) 1년 기간 적용의 불가능성

- 처분이 있는 날부터 1년의 규정은 처분이 있었으나 이를 현실적으로 알지 못한 경우에 한하여 보충적으로 적용되는 객관적 제소기간이다. 그러나 일반처분의 법리에 의해 乙은 이미 2024. 5. 31.에 처분을 안 것으로 법적 평가를 받으므로, 안 날부터 90일의 제한을 우선적으로 적용받게 된다. 따라서 1년의 기간이 남아있다 하더라도 이미 90일의 불변기간이 도과하였다면 소는 부적법해진다.

III. 법적 안정성과 구체적 타당성의 충돌

1. 가혹성 인정 (구체적 타당성의 침해)

- 개인의 과실이 없음에도 불구하고 단지 해외에 체류했다는 이유로 소송 기회를 원천 차단당하는 것은 자기책임 원칙 및 헌법상 재판청구권(제27조)의 실질적 보장 측면에서 매우 가혹한 처사임이 분명하다.

2. 행정의 법적 안정성 및 통일성 확보의 필요성

- 그럼에도 불구하고 대법원이 이를 엄격히 관철하는 이유는 일반처분의 특수성 때문이다. 일반처분은 불특정 다수인을 대상으로 하는 규율이므로, 만약 개개인이 실제로 안 날을 기준으로 제소기간을 개별 산정한다면 동일한 행정명령(예 : 감염병 집합금지명령)의 효력이 수개월 혹은 1년이 지난 후에도 개별 소송에 의해 흔들릴 수 있다. 이는 행정법 관계의 조속한 안정을 해치고 행정의 통일적 집행을 불가능하게 만드는 치명적인 결과를 초래한다.

IV. 소송법상 대안적 구제 수단의 검토

1. 소송행위의 추후보완 (추완) 가능성 검토

(1) 규정 및 요건

- 행정소송법 제8조 제2항에 의해 민사소송법 제173조가 준용된다. 처분이 있음을 안 날부터 90일은 불변기간이므로, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 이를 준수하지 못한 경우 그 사유가 없어진 날부터 2주일(외국에 있던 자는 30일) 이내에 게을리한 소송행위를 보완(소 제기)할 수 있다.

(2) 판례의 엄격한 태도

- 해외 체류로 인해 공고 사실을 알 수 없었다는 사정이 과연 책임질 수 없는 사유에 해당하는지가 관건이다. 판례는 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간에 대해서는 천재지변이나 이에 준하는 극단적인 사정이 없는 한 단순히 해외 체류 등의 사정만으로는 소송행위의 추완을 인정하지 않는 매우 보수적인 태도를 견지한다. 이는 고시·공고의 대외적 공정력과 객관적 가치를 중시한 결과이다.

2. 국가배상청구소송을 통한 우회적 구제

- 만약 집합금지명령 자체의 위법성으로 인해 乙에게 심각한 재산상 손실이 발생했고 취소소송의 기한을 놓쳤다면, 乙은 처분의 위법성을 이유로 한 국가배상청구소송(민사소송)을 제기할 수 있다. 소멸시효는 손해 및 가해자를 안 날부터 3년이므로 제소기간보다 훨씬 여유가 있으며, 법원은 이 소송에서 처분의 위법 여부를 선결문제로 판단할 수 있다.

V. 결론 및 입법론적 제언

- 현행법과 판례 체계하에서 乙의 소송을 적법한 제소기간 내의 소로 유효하게 다루는 것은 불가능하다. 있는 날부터 1년의 독자적 적용을 허용할 경우 일반처분의 존속력이 장기간 불안정한 상태에 놓이게 되며, 이는 전체 행정법 관계의 혼란으로 이어지기 때문이다. 결국 법원은 구체적 타당성을 희생하더라도 법적 안정성을 수호하는 방향을 선택할 수밖에 없다. 다만, 이러한 사법적 한계를 극복하기 위해서는 입법론적인 보완이 필요하다. 해외 체류자 등 정당한 사유로 고시를 인지하지 못한 것이 객관적으로 증명된 경우에 한하여 예외적으로 소송행위의 추완 요건을 완화해 주는 명문의 규정을 두거나, 국가가 중대한 영업 제한 처분을 내릴 때는 공고 외에도 행정절차법상 가능한 범위 내에서 업종별 대표자나 등록된 업주들에게 문자 송신 등의 보완적 통지 제도를 강화함으로써 국민의 실질적 구제와 행정의 안정성을 조화롭게 달성해야 할 것이다.

<관련판례>

- 대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결